

0001606-43.2020.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... (RJTJSP 75/343).

Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- Pretensão de absolvição por falta de provas ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

0001606-43.2020.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001606-43.2020.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Aparecido dos Santos Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS SILVA e ADRIANO FERREIRA LEITE, já devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", ambos c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal.

Constou da denúncia que, no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 16h40min, na Rua Bilak, n.º 500, Vila Real, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, os réus teriam trazido consigo, para venda a terceiros, 08 (oito) porções de maconha, pesando cerca de 19,3g; 01 (uma) porção de cocaína, pesando cerca de 5,6g; e 19 (dezenove) porções de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 16,7g, substâncias essas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06, laudo de constatação de fls. 27/29).

Constou ainda, que em datas não apuradas, mas no ano de 2019, nesta cidade e

comarca de Várzea Paulista, os réus teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes.

Constou por fim, que os fatos se deram nas proximidades da Escola Estadual Armando Dias.

A ação penal foi autuada sob o número 1503003-42.2019.8.26.0544, mas com o desmembramento em relação ao réu RAFAEL, surgiram estes autos de número 0001606-43.2020.8.26.0655.

O réu RAFAEL inicialmente não foi localizado para fins de notificação (pág. 97/104). Posteriormente, compareceu em cartório (pág. 133). Fora novamente tentado sua notificação e intimação para a audiência virtual, tendo o mandado retornado NEGATIVO (pág. 150 e 195). Por fim, fora notificado por EDITAL (pág. 206/207).

Na sequência, o réu RAFAEL foi pessoalmente notificado (pág. 294/295) e apresentou defesa prévia (pág. 107/111 e 285/293).

Na defesa prévia, argumentou a Defesa do réu RAFAEL que sua confissão na fase policial não é suficiente para sua condenação. Argumentou que as provas existentes não são suficientes para embasar a condenação. Pugnou pelo afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, porque não há provas, de que a mercancia visava os alunos da escola. Ao final, pugnou por sua absolvição e arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Recebida a denúncia em 02 de março de 2020 (pág. 112/113).

Em audiência de instrução dos autos de número 1503003-42.2019.8.26.0544, foi ouvido o corréu ADRIANO, bem como foram ouvidas as testemunhas arroladas. Nessa mesma oportunidade, o réu ADRIANO foi condenado pelo delito de tráfico e absolvido pelo delito de associação para o tráfico. Fora ainda determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu RAFAEL e, ainda, que as provas colhidas seriam utilizadas como provas emprestadas, considerando a presença da advogada do réu RAFAEL em audiência (pág. 220/238).

Na audiência de instrução, foi colhido o depoimento de uma testemunha e, por fim, o réu RAFAEL foi interrogado.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se o réu RAFAEL nos termos da denúncia. Em seguida a Defesa pugnou pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 03/04), pelo boletim de ocorrência (pág. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 08), pelo mapa do local dos fatos (pág. 28), pelo laudo pericial do LOCAL DOS FATOS (pág. 244/246), pelo laudo de constatação (pág. 29/31), pelo exame químico toxicológico definitivo (pág. 147/149), com resultado positivo para MACONHA e COCAÍNA, bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo.

Das provas colhidas em Juízo:

Na fase policial o réu RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS SILVA, assim relatou:

"Informo que tenho uma filha, que possui seis meses, a qual está com a minha amásia. Nunca fui preso anteriormente. Sou usuário de cocaína e maconha. Fui cientificado acerca dos meus direitos constitucionais. Conheço Adriano Ferreira Leite, o qual é primo da minha amásia. Adriano me chamou para vender drogas com ele, sendo que eu ficava na "contenção", ou seja, ficava controlando o acesso dos usuários e também deveria me atentar com a chegada da polícia. Já Adriano carregava as drogas a serem entregues aos usuários e ficava com o dinheiro conseguido com a traficância. No fim do "expediente" eu e Adriano dividíamos o lucro obtido com a venda das drogas. Há algumas semanas estava vendendo entorpecentes com Adriano, o fazia diariamente das 07:00 às 19:00; recebia por dia entre R\$ 100,00 e R\$ 200,00. Hoje estava vendendo drogas com Adriano, quando avistei uma viatura descaracterizada adentrando na viela, gritei para Adriano e saí correndo. Adriano colocou as drogas em um bueiro; e então descemos uma escadaria que iria até a rua Nestor Alves, ao chegar no fim da escadaria nos deparamos com policiais, onde fomos abordados e revistados. Adriano carregava o dinheiro que havíamos conseguido vendendo drogas. Ao ser cientificado que eu havia sido visto vendendo drogas com Adriano, confessei aos policiais que vendia entorpecentes junto com Adriano. Fui bem tratado pelos policiais, nada tendo a reclamar. Não quero avisar ninguém que fui preso". Em juízo informou que estava no local dos fatos fumando maconha, e quando viu um policial próximo ao local dos fatos, o depoente se assustou e fugiu. Que conhecia Adriano. Que não comprou as drogas de Adriano. Que já havia comprado a maconha em outra oportunidade, indo até o local apenas para fumar. Que é usuário de maconha há muitos anos. Que não se recorda do que falou na delegacia. Que os policiais lhe deram um murro. Que se sentiu oprimido na delegacia. Que o local dos fatos era distante do local onde Adriano se encontrava. Que o Adriano é tio de sua mulher.

Por sua vez, o policial civil ALEXANDRE DE FREITAS CAPELLO, assim esclareceu na fase policial:

"Informo que acompanhado do Policial Civil Vagner realizava diligências pela cidade de Várzea Paulista, quando no interior de uma viela, localizada na Rua Bilak, nas proximidades da Escola Estadual Armando Dias, local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizamos os indiciados, Rafael Aparecido Santos Silva e Adriano Ferreira Leite. O indiciado Rafael estava na confluência das duas vielas, já o indiciado Adriano estava mais abaixo, próximo de uma escadaria, carregando uma sacola plástica. Assim, passamos a realizar observação dissimulada e depois de algum tempo chegou no local um transeunte, o qual se aproximou do indiciado Rafael, que indicou a ele o indiciado Adriano. O transeunte então desceu, foi até o indiciado Adriano e lhe entregou algo. O indiciado Adriano, colocou o que recebeu no bolso da sua bermuda e do interior da sacola que carregava retirou algo e entregou ao transeunte, que dali saiu. Logo em seguida outro transeunte se aproximou do indiciado Rafael, que novamente indicou o indiciado Adriano. Este transeunte foi até o indiciado Adriano e lhe entregou algo. O indiciado Adriano colocou no bolso da sua bermuda o que recebeu do transeunte, retirou algo do interior da sacola e lhe entregou. Enquanto está troca de mãos ocorria, chegaram dois transeuntes, sendo estes interpelados pelo indiciado Rafael, que ficou com eles. No momento que o transeunte subiu, apenas um dos indivíduos desceu ao encontro do indiciado Adriano, sendo que o outro indivíduo ficou juntamente com o indiciado Rafael. O indivíduo foi até o indiciado Adriano e lhe entregou algo, novamente o indiciado Adriano colocou o que recebeu no bolso da sua bermuda, retirou algo do interior da sacola que carregava e entregou a este indivíduo, que subiu, se juntou ao rapaz que o acompanhava anteriormente, que estava ao lado do indiciado Rafael, e os dois dali saíram. Em face a movimentação característica da comercialização de drogas, resolvemos abordar os indiciados. Fiquei postado no fim da escadaria, na Rua Nestor Alves, já o policial Vagner foi até a Rua Bilak e adentrou na viela. Ao adentrar na viela, o indiciado Rafael gritou para o indiciado Adriano: "molhou...polícia" (sic) e foi correndo em direção ao indiciado Adriano. Neste momento o indiciado Adriano colocou a sacola que carregava em um bueiro, se

juntou a Rafael e desceram a escadaria, sendo acompanhados pelo policial Vagner. No fim da escadaria abordei os dois indiciados, que eram acompanhados pelo policial Vagner, que também os abordou. Os indiciados então foram algemados e revistados. O indiciado Rafael nada carregava; já o indiciado Adriano carregava a quantia de R\$ 40,00 no bolso da sua bermuda. Ao serem cientificados que estávamos os observando, os indiciados nos confessaram que vendiam entorpecentes, que estavam na sacola que o indiciado Adriano carregava, que havia escondido no bueiro. Em seguida nos dirigimos até o bueiro, onde localizamos a sacola plástica que o indiciado Adriano havia escondido, na qual havia 01 tubete plástico com cocaína, 08 invólucros plásticos com maconha e 19 tubetes plásticos com crack. Demos voz de prisão aos indiciados, que foram conduzidos até esta Especializada". O que foi ratificado em juízo. Em complemento esclareceu que não o conhecia os réus antes dos fatos. Em decorrência do falecimento da testemunha, não foi ouvido em Juízo.

Por fim, o policial civil VAGNER CAPALBO, assim relatou na fase policial:

"Esclareço que juntamente com o Policial Civil Alexandre diligenciava pela cidade de Várzea Paulista, sendo que no interior de uma viela, localizada na Rua Bilak, nas proximidades da Escola Estadual Armando Dias, local já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas, avistamos os indiciados, Rafael Aparecido Santos Silva e Adriano Ferreira Leite. O indiciado Rafael estava na confluência das duas vielas, já o indiciado Adriano estava mais abaixo, próximo de uma escadaria, carregando uma sacola plástica. Resolvemos então realizar "campana" e depois de algum tempo chegou no local um transeunte, o qual se aproximou do indiciado Rafael, que indicou a ele o indiciado Adriano. O transeunte então desceu, foi até o indiciado Adriano e lhe entregou algo. O indiciado Adriano, colocou o que recebeu no bolso da sua bermuda e do interior da sacola que carregava retirou algo e entregou ao transeunte, que dali saiu. Logo em seguida outro transeunte se aproximou do indiciado Rafael, que novamente indicou o indiciado Adriano. Este transeunte foi até o indiciado Adriano e lhe entregou algo. O indiciado Adriano colocou no bolso da sua bermuda o que recebeu do transeunte, retirou algo do interior da sacola e lhe entregou. Enquanto esta troca de mãos ocorria, chegaram dois transeuntes, sendo estes interpelados pelo indiciado Rafael, que ficou com eles. No momento que o transeunte subiu, apenas um dos indivíduos desceu ao encontro do indiciado Adriano, sendo que o outro indivíduo ficou juntamente com o indiciado Rafael. O indivíduo foi até o indiciado Adriano e lhe entregou algo, novamente o indiciado Adriano colocou o que recebeu no bolso da sua bermuda, retirou algo do interior da sacola que carregava e entregou a este indivíduo, que subiu, se juntou ao rapaz que o acompanhava anteriormente, que estava ao lado do indiciado Rafael, e os dois dali saíram. Diante da movimentação típica da venda de drogas, resolvemos abordar os indiciados. O policial Alexandre ficou postado no fim da escadaria, na rua Nestor Alves, eu fui até a Rua Bilak e adentrei na viela. Ao adentrar na viela, o indiciado Rafael gritou para o indiciado Adriano: "molhou...polícia" (sic) e saiu correndo, indo na direção do indiciado Adriano. Por sua vez, o indiciado Adriano colocou a sacola que carregava em um bueiro, se juntou ao indiciado Rafael e desceram a escadaria, eu os acompanhando. No fim da escadaria os dois indiciados foram abordados pelo policial Alexandre, eu os acompanhava e também os abordei. Algemamos os indiciados e os revistamos. O indiciado Rafael nada carregava; já o indiciado Adriano carregava a quantia de R\$ 40,00 no bolso da sua bermuda. Cientificamos os indiciados que estávamos os observando e estes nos confessaram que vendiam entorpecentes, os quais estavam na sacola que o indiciado Adriano carregava e havia escondido no bueiro. Fomos ao bueiro, onde encontramos a sacola plástica que o indiciado Adriano havia escondido, na qual havia 01 tubete plástico com cocaína, 08 invólucros plásticos com maconha e 19 tubetes plásticos com crack. Demos voz de prisão aos indiciados, que foram conduzidos até esta Especializada". O que foi ratificado em juízo. Que o local dos fatos é próximo a escola Armando Dias. Que do local onde estava não conseguia ouvir o que o réu falava. Que haviam residências no local dos fatos.

Do Valor e do Conjunto das Provas:

Dos Depoimentos dos Policiais Civis:

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Face as provas colhidas nos autos, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava dividida, bem como, os depoimentos seguros prestados pelos agentes, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação. Nessa linha: "Apelação – Justiça Pública – Tráfico de Drogas – Condenação – Necessidade – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 20 pedras de crack – Depoimentos seguros e harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante – Suficientes elementos para embasar a condenação – Pena – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Incidência da circunstância agravante da reincidência – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas por ausência de preenchimento dos requisitos – Imposição de Regime Fechado. Recurso de Apelação provido para condenar o réu André da Silva Ferreira à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 583 dias multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 2006, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do réu, após o trânsito em julgado." (Apelação nº 0006970-48.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas. 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: César Augusto Andrade de Castro. Julgado em 29/04/2015).

Do Pedido de Desclassificação do Delito:

Diante o conjunto probatório dos autos, demonstrando-se claramente a traficância, não se autoriza a pretendida desclassificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06).

Anoto que nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e face as demais provas colhidas nos autos, competia ao requerido comprovar que seria apenas usuário de entorpecentes, o que não foi feito.

Neste sentido: "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343).

Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). APELAÇÃO TRÁFICO DE

DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- Pretensão de absolvição por falta de provas ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06 Impossibilidade - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos - Versão do réu restou incomprovada - Palavras dos policiais civis - Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública e foram corroborados pelas demais provas Traficância - Condenação era de rigor - Penas e regime inicial fechado corretamente aplicados- Impossibilidade de substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos - Recurso defensivo desprovido. (Apelação nº 3009705-74.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo. 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Edison Brandão. Julgado em 12/05/2015). EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Apelo do réu objetivando a absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos. Razoável quantidade de cocaína apreendida, além de grande quantia em dinheiro trocado. Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório- Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Gravidade concreta da conduta do apelante que revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Recurso improvido. (APELAÇÃO Nº 0002426-75.2011.8.26.0397. Comarca de Nuporanga. 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Moreira da Silva. Julgado em 12/02/2015).

Do Crime de Tráfico:

O crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em “trazer consigo e vender” a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

No caso em tela, restou devidamente comprovado que os policiais civis realizavam diligências em local já conhecido como ponto de venda de drogas, com viatura descaracterizada, quando na entrada de uma viela, localizada na Rua Bilak, nas proximidades da Escola Estadual Armando Dias, visualizaram os réus RAFAEL e ADRIANO.

Esclareceram que o réu RAFAEL estava na confluência das duas vielas, já o réu ADRIANO estava mais abaixo, próximo de uma escadaria, carregando uma sacola plástica. Através da observação dissimulada, visualizaram um transeunte que chegou ao réu RAFAEL, e este o indicou ao réu Adriano. O transeunte então desceu até o réu ADRIANO, lhe entregou algo, que foi pego e colocado no bolso de sua bermuda. Na sequência o réu ADRIANO pegou algo da sacola plástica e entregou ao transeunte, o qual saiu em seguida do local.

Após visualizarem por três vezes os fatos acima descritos, os policiais resolveram realizar a abordagem e cercaram a viela. Quando um dos policiais adentrou na viela, o réu RAFAEL saiu correndo em direção ao réu ADRIANO gritando “molhou ... polícia”. O réu ADRIANO jogou a sacola plástica no bueiro e igualmente saiu correndo. Contudo ambos foram detidos.

Os policiais conseguiram recuperar a sacola plástica jogada no bueiro pelo réu

ADRIANO, e no seu interior encontraram: 01 (uma) porção de cocaína, 08 (oito) porções de maconha e 19 (dezenove) porções de crack, todas embaladas individualmente, prontas para a mercancia. E no bolso da bermuda do réu ADRIANO, ainda encontraram a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 08.

O réu RAFAEL, formalmente na fase policial, confessou a prática do crime. Esclareceu que o réu ADRIANO é primo de sua companheira, e como estava desempregado, resolveu ir trabalhar com ele. Informou que sua função era ficar na "contenção", ou seja: ficava controlando o acesso dos usuários e também deveria se atentar com a chegada da polícia. Aduziu que o réu ADRIANO é quem ficava com as drogas e as vendia, e no final do expediente, dividiam os lucros. Informou que trabalhavam diariamente juntos das 07h00min às 19h00min, e isso já se dava há algumas semanas. Diariamente, conseguia receber de R\$ 100,00 a R\$ 200,00.

Portanto, restou mais do que demonstrado nos autos, que o réu RAFAEL praticou o delito de tráfico de entorpecentes, não podendo se acolher sua versão trazida nesta data.

Vale ainda consignar, que não há motivos para se duvidar das palavras dos policiais civis, que nem ao menos conheciam o réu, e não teriam qualquer motivo para incriminá-lo. Portanto, cabia ao réu provar o contrário, fato do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Verifico ainda, que o artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 traz dezoito núcleos para a caracterização do tipo penal, e qualquer deles é mais do que o suficiente para a caracterização do delito.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Diante do exposto, a condenação do réu RAFAEL é medida que se impõe, nos termos do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

De se destacar que a confissão na fase policial do réu, ainda que não ratificada nesta oportunidade, foi corroborada em Juízo com a prova testemunhal colhida e com os demais elementos colhidos nos autos e, portanto, pode ser empregada como elemento de prova.

Crime de Associação para o Tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006):

O réu RAFAEL também foi denunciado como incurso no artigo 35, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de que teria se associado ao réu ADRIANO, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes.

Ao que constou da denúncia, os réus estariam se associando, uma vez que RAFAEL fazia a contenção dos clientes, enquanto o ADRIANO fazia as vendas.

Assim disciplina o artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa".

Pois bem.

Em seu depoimento o réu RAFAEL negou a prática da associação para o tráfico de entorpecentes.

Para a caracterização do crime em questão, necessário se faz a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa. Deve existir o ânimo associativo de forma estável e duradoura, com a finalidade de cometer os crimes previstos na referida lei.

Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para o crime de tráfico. Para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, e desse ônus não se desincumbiu o(a) representante do Ministério Público.

Para que se condenem os réus como incursos no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, necessária prova concreta nesse sentido, e a princípio, tal prova não restou comprovada nos presentes autos já que as testemunhas ouvidas em Juízo não confirmaram tal fato. Nessa mesma esteira, colaciono as decisões dos Tribunais:

“Apelação. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição. Defesas que pretendem a absolvição dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 ou a desclassificação para o tipo descrito no artigo 28, da referida Lei de Drogas (em relação ao corréu Leonardo). Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus por tráfico e associação para o tráfico. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, do referido diploma legal. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, aliadas à caracterização do crime de associação que inviabilizam a concessão da benesse. Insuficiência probatória no tocante ao crime de posse irregular de munição em relação aos corréus Leonardo e Elielson. Penas que comportam reparo. Regime prisional bem justificado. Quantidade de pena aplicada que afasta a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos defensivos parcialmente providos para absolver os réus Leonardo e Elielson quanto ao crime descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 e redimensionar as penas de todos os acusados.” (Apelação nº 0009903-30.2013.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá. 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Sérgio Coelho. Julgado em 03/12/2015).

É ainda de se observar, que o réu ADRIANO foi absolvido por tal delito (pág. 220/238).

Portanto, levando em consideração o princípio do “in dubio pro reo”, não há que se falar na configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, devendo o réu ser absolvido.

Do artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006:

Constou da denúncia, que o réu RAFAEL teria cometido os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, nas imediações do estabelecimento de ensino.

Conforme os depoimentos dos policiais civis, verifica-se que o delito de tráfico de entorpecentes estava sendo praticado na rua ao lado da Escola Estadual Armando Dias, qual seja: na Rua Bilak, conforme mapa do local dos fatos (pág. 28).

E o laudo pericial do LOCAL DOS FATOS confirma que o delito estava sendo praticado a 10 metros de distância da Escola Estadual Armando Dias (pág. 244/246).

O artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, assim disciplina:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. (grifo nosso).

Restou demonstrado nos autos, que de fato o delito era praticado na rua ao lado da Escola Estadual Armando Dias, que é estabelecimento de ensino, causando desequilíbrio social e desarmonia, razão pela qual a pena deve ser aumentada nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Validade dos depoimentos dos agentes públicos. Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia. Majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 que é de caráter objetivo, bastando que o delito seja praticado nas proximidades dos estabelecimentos elencados no referido dispositivo legal, como “in casu”. Condenação bem lançada. Pena criteriosamente aplicada. Doute maioria que entende que a figura privilegiada não retira o caráter hediondo do delito, sendo incabíveis a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade. Recurso defensivo desprovido, por maioria”. (Apelação 0017626-70.2016.8.26.0196 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Camilo Léllis, DJe 19/06/2018).

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. POSSIBILIDADE. PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação “per relationem”. Precedentes do STF. 2. Restou comprovado que o réu praticou o crime de narcotráfico próximo a local de cunho educativo, um estabelecimento de ensino, de sorte que a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, deve ser reconhecida. Por sinal, é da prova oral judicial que o réu foi encontrado próximo a uma escola, com razoável quantidade de drogas, lugar que possui várias crianças e adolescentes, ou seja, vulneráveis à ação do narcotraficante. Precedentes do STF e do STJ. Inteligência da doutrina. 3. Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a quantidade do entorpecente apreendido demonstra que a substituição da reprimenda corporal por

restritiva de direitos não seria suficiente para a reprovação e a prevenção do crime em comento. 5. Provimento do recurso do Ministério Público." (Processo: APL 00071532720138260197 SP 0007153-27.2013.8.26.0197, Relator(a): Airton Vieira, Julgamento: 30/04/2015, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Publicação: 15/05/2015).

Passo a dosar a pena:

Do Crime de Tráfico:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que o réu não possui maus antecedentes. As demais circunstâncias judiciais são punidas pela própria tipicidade do delito, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a atenuante da CONFISSÃO, porém, estando a pena no mínimo legal, não é caso de diminuição da pena.

Na terceira fase de aplicação da pena, considerando a natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas e a variedade (08 porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 19 (dezenove) porções de crack), e ainda, considerando que o próprio réu, na fase policial, confirmou que trabalhava há semanas no local das 07h00min às 19h00min, demonstrando seu envolvimento com organização criminosa, não vislumbro ser o caso de aplicação do privilégio, motivo pelo qual deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ainda na terceira fase de aplicação da pena, como bem demonstrado nos autos, está presente a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou o crime ao lado da "Escola Estadual Armando Dias", sendo assim, aumento a pena em 1/6, resultando em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, esta pena torna-se definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado a hediondo, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente FECHADO, como expressamente previsto no artigo 2º, inciso II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 11.464/07.

Outrossim, as circunstâncias do caso em tela revelam, mormente pela natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas, "maconha", "cocaína" e "crack", se desse modo que ele conseguia o seu sustento, certo que a "cocaína" e o "crack" são os tipos de substâncias entorpecentes que reclamam, para a sua produção, a posse de um laboratório especializado, o que não consta ser possuído pelo réu, razão que se impõe, mesmo, o regime prisional mais gravoso. Não bastasse, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem do réu estão a impor, ainda com maior razão, o regime prisional fechado, não se perdendo de vista a correlação entre o art. 59, "caput" e o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal.

Não se faz presente a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, porque tais benefícios

são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez.

Acerca da constitucionalidade da vedação à conversão da pena privativa de liberdade em sanção alternativa, nesse sentido, aliás, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, ponderando que embora tenha o Supremo Tribunal Federal afirmado ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, rel. Min. Ayres Brito), deve ser ressalvado que tal decisão foi adotada em sede difusa, por maioria de votos e sem efeito vinculante (cf. HC 168.459/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/10).

Ressalto que o delito em questão, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros crimes tão ou mais graves e intimamente ligados com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias.

Do valor do dia-multa:

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei n. 11.343/06, sendo fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos que pudesse majorar tal pena.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização crimínosa – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal pública que o Ministério Público move em face de RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS SILVA, já devidamente qualificado, para o fim de:

- a) CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06;
- b) ABSOLVÊ-LO nos termos do artigo 386, inciso VII (não existir prova suficientes para a condenação), do Código de Processo Penal, com relação ao delito descrito no artigo 35, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o réu está respondendo ao presente processo em liberdade, e

compareceu nesta data para o interrogatório, entendo que, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, não há que se decretar sua prisão.

Consigno que, ao que consta, os valores encontrados estavam com o réu ADRIANO, sendo que já foi declarado o perdimento em favor da União.

Dos Efeitos da Condenação:

Custas na forma da lei.

Autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida. Se o caso, oficie-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arbitro em favor d(a)o(s) advogado(a) conveniado(a)(s) honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça a(s) certidão(ões).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Paulista, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.